

1500894-70.2021.8.26.0581

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Regina Figueiredo

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... de forma distinta, senão que ambas visavam o tráfico, devendo, portanto, a conduta do cultivo das plantas que se constituem em matéria prima para o preparo do entorpecente ser considerado crime meio, devendo ser absorvido pelo crime previsto artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

"Apelações criminais - Tráfico de substância entorpecente - Sentença condenatória ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

2ª Vara

Rua Ettore Targa, s/n, São Manuel - SP - cep 18650-000

1500894-70.2021.8.26.0581 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500894-70.2021.8.26.0581

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PEDRO MARQUES DA SILVA

Vistos.

JOAO PEDRO MARQUES DA SILVA, qualificado nos autos da ação penal em epígrafe que lhe move a Justiça Pública, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput e artigo 33, §1º, inciso II, ambos da Lei 11.343/06.

Isso porque, no dia 12 de agosto de 2021, por volta das 11h30min, na Rua José Ambrozim, nº 123, Cohab III, na cidade de São Manuel, o acusado guardava e tinha em depósito, em sua residência, 01(uma) porção de "maconha", pesando 54,32 g (cinquenta e quatro gramas e trinta e duas centigramas), bem como cultivava, no quintal do mesmo local, 05 (cinco) pés de "Cannabis sativa", planta que se constitui em matéria-prima para a preparação de drogas, ambas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão e laudo pericial provisório juntado aos autos.

O réu foi preso em flagrante delito e o expediente policial distribuído livremente a este juízo que, após a manifestação das partes, decidiu pela concessão de liberdade provisória mediante a fixação de medidas cautelares outras. (p.60/62)

Oferecida denúncia aos dias 13 de setembro de 2021, o réu foi devidamente notificado na p.101 e ofertou defesa preliminar na p. 106, sendo a denúncia recebida por decisão datada de 13 de outubro de 2021 (p. 112/113).

Durante a instrução, realizada por videoconferência consoante o disposto na Recomendação CNJ n.314/2020, Provimentos n. 2564/2020 e Comunicados CG 284/2020, 317/2020 e 581/2020, o réu foi interrogado, bem como ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia, conforme gravação audiovisual juntada aos autos. (p.143 e 155)

Encerrada a instrução criminal, o i. Representante do Ministério Público apresentou suas alegações finais orais, requerendo a condenação dos acusados nos termos da exordial, com a fixação do regime inicial fechado.

A n. Defesa técnica dos réu, a seu turno, pugnou por sua absolvição sustentando a insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou a desclassificação do delito imputado na denúncia para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 e, em caso de eventual condenação, a aplicação da pena base em seu mínimo legal, sustentando que circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

É o breve relatório.

DECIDO.

Não havendo questões preliminares ou de admissibilidade a analisar e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A procedência parcial do pedido inicial é medida que se impõe, senão vejamos:

A materialidade restou suficientemente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de p. 05/06, Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida de p. 13/15, Auto de Exibição e Apreensão de p. 31/32 e Laudo Químico-Toxicológico Definitivo de p. 140/142, que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida com resultado positivo para Cannabis sativa L- maconha.

No que concerne à autoria, observo que, em solo policial, o acusado João Pedro Marques da Silva admitiu a propriedade da droga apreendida, bem como que havia plantado cinco pés de maconha, alegando que se destinavam a seu próprio consumo (p.11/12).

Em juízo, disse que, no dia dos fatos, estava conversando na rua com um pessoal quando a polícia se aproximou buzinando e apontando um revólver, sendo abordado dentro de sua casa. No mais, alegou que adquiriu a porção de maconha apreendida dentro do imóvel para seu consumo, com dinheiro proveniente dos "bicos" de pintura e carpintaria, origem dos R\$90,00 que foram apreendidos, e que cultivadas plantas de maconha no seu quintal também para consumi-las, a fim de não precisar ficar indo em biqueiras, já que ostenta condenação anterior pela prática do tráfico ilícito de entorpecente. Não se recordou dos policiais terem apreendidos cinquenta saquinhos plásticos comumente utilizados para embalar as drogas individualmente. Por fim, disse que já conhecia os policiais porque eles já haviam prendido seu tio no mesmo imóvel onde nasceu e cresceu.

Marcelo Alexandre Ribeiro Ferreira, policial civil, relatou que, na data dos fatos, realizava patrulhamento para coibir a prática do tráfico nas "biqueiras" desta cidade e, ao passar em frente a residência do acusado, o visualizou em atitude suspeita, motivo pelo qual resolveu aborda-lo, por já ser conhecido dos meios policiais pela prática da traficância. Que nada de ilícito foi apreendido em seu poder, porém, ao olhar pela fresta do portão, visualizou quatro possíveis pés de maconha em um canteiro. Que bateu palmas e foi atendido por um senhora de idade que se apresentou como avó do acusado e autorizou que adentrassem ao imóvel, quando então constou que realmente se tratavam de cinco pés de maconha, tendo o acusado admitido seu cultivo. Que sua avó informou que, possivelmente, havia mais drogas no quarto dele, onde encontrou cerca de R\$90,00 em dinheiro, bem como um pote, em cima de um criado mudo, contendo cerca de 60g de maconha, pronta para ser embalada, um colher com resquícios da droga e saquinhos comumente utilizados para embalar entorpecentes. Que o acusado alegou que as drogas apreendidas e as plantas de maconha eram destinadas a seu consumo pessoal. Que não foi abordado nenhum usuário na data dos fatos. Por fim, disse que optou por não conduzir a avó do acusado à Delegacia de Polícia em razão da idade e por apresentar problemas de saúde.

No mesmo sentido foram as declarações do também policial civil Rogério Aparecido Guiari, acrescentando, apenas, que no quarto do acusado também foi apreendida uma tesoura.

A cabo da instrução criminal, nota-se que a negativa de autoria sustentada pelo réu em Juízo, alegando que a expressiva quantidade da droga apreendida em seu quarto era para seu consumo no mês, mostra-se demasiadamente frágil e inconvincente, desprovida de qualquer adminículo probatório.

A uma, porque não logrou comprovar sua condição de usuário de drogas por meio de documentos e/ou testemunhas; a duas, porque sequer declinou o nome da pessoa para qual prestou o suposto serviço que lhe rendeu o dinheiro com o qual adquiriu essa droga; a três, porque também foram apreendidos saquinhos plásticos comumente utilizados para embalar drogas, cuja existência o réu, simplesmente, disse que desconhecia.

Vale ressaltar que para aferir se a droga se destinava a consumo pessoal, ou ao tráfico, deve-se verificar a quantidade de substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, conforme dispõe o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11343/06.

E na hipótese, os policiais civis ouvidos foram seguros e convincentes ao declararem que o réu foi abordado em conduta típica da traficância em que ficam sentado em frente do imóvel aguardando possíveis usuários.

Oportuno consignar que os policiais, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, são merecedores de confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer e, efetivamente, merece, até que se prove o contrário.

A respeito do tema a jurisprudência:

"É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ. [...] 8. Habeas corpus não conhecido." (HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017)." (STJ - HC: 530794 SP 2019/0261161-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 06/08/2020).

A par disso, in casu, houve a apreensão de 69,97 g (sessenta e nove gramas e noventa e sete centigramas) de maconha (p.35) e, "conforme decisão publicada na RT 546/327, para se fazer um cigarro de maconha tipo fininho ou bagana, basta 0,33g da referida droga" (Apelação nº 0027947-56.2015.8.26.0114, 9ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Júlio Caio Farto Salles, j. em 05/04/2018).

Destarte a prática da traficância emerge do contexto fático narrado, desde a abordagem policial, a expressiva quantidade de droga apreendida no quarto do acusado, junto com petrechos comumente utilizados para embala-las, a plantação de cinco plantas destinadas ao preparo da droga e a apreensão de quantia em dinheiro sem comprovação de sua origem lícita.

Outrossim, ainda que considerada verídica sua condição de usuário de entorpecentes, o que, repito, não restou comprovado nos autos, é sabido que nada impede a coexistência das duas figuras - usuário e traficante, o que se conclui pelas condições e circunstâncias que o acusado foi detido em local conhecido como ponto de venda de drogas, na posse de expressiva quantidade de maconha que, a toda evidência, não poderia se destinar a uma só pessoa, o que afasta a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de drogas.

Ressalte-se que o delito em tela restou plenamente consumado, ainda que o réu não tenha sido visto efetivamente comercializando drogas em virtude da pronta e eficiente ação da polícia, que o prendeu em flagrante antes disso, já que o artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 prevê um tipo penal de ação múltipla alternativa, de modo que a realização de apenas uma das condutas nele descritas já é suficiente para a sua configuração, como a praticada pelo acusado de guardar e ter em depósito drogas destinadas ao consumo de terceiras pessoas.

A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.(REsp 1708569)

Noutro giro, as circunstâncias fáticas da prisão do acusado não demonstram a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a atingir o bem jurídico tutelado de forma distinta, senão que ambas visavam o tráfico, devendo, portanto, a conduta do cultivo das plantas que se constituem em matéria prima para o preparo do entorpecente ser considerado crime meio, devendo ser absorvido pelo crime previsto artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

"Apelações criminais - Tráfico de substância entorpecente - Sentença condenatória - Recurso defensivo voltado à absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos - Razoável quantidade de maconha apreendida, dividida em diversas porções individuais, prontas para entrega ao consumo, inviabilizando o pleito desclassificatório - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório. Recurso defensivo não provido. Recurso ministerial voltado à majoração da pena-base, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade de entorpecentes e personalidade do agente), à condenação pelo delito do artigo 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06 e ao prequestionamento da matéria - Admissibilidade parcial - Aplicação do princípio da consunção - Ato de cultivar a matéria-prima que constitui meio para a prática do tráfico, sendo por este absorvido - Penas alteradas - Elevação da pena-base em razão da maior reprovabilidade da conduta, pois o agente cultivava a matéria-prima da droga e traficava o entorpecente ao mesmo tempo, sendo apreendida com ele grande quantidade de maconha - Regime prisional mantido, ante a gravidade concreta da ação criminosa, reveladora da elevada danosidade social do paciente. Recurso ministerial parcialmente provido."(TJ-SP 00080180620158260286 SP 0008018-06.2015.8.26.0286, Relator: Moreira da Silva, Data de Julgamento: 12/04/2018, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/04/2018).

Em remate, diante do conjunto probatório coligido nos autos, não resta a menor dúvida da traficância praticada pelo acusado.

Passo a dosar a pena.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42, da Lei n. 11.343/06, notadamente a reincidência do acusado, conforme se observa da sua F.A de p.134/136 e certidão de p.137/138, o que será considerando no momento oportuno, fixo a pena base no seu mínimo legal de 5(cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias multa).

Presente a circunstância agravante decorrente da reincidência do réu, (autos n. 1500626-50.2020.8.26.0581), razão pela qual aumento a pena aplicada em 1/6(um sexto), resultando em 5(cinco) anos e 10(dez)meses de reclusão e 583(quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Não há circunstâncias atenuantes a considerar, tampouco causa de aumento de pena. Inaplicável a causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 que é para casos especialíssimos, não sendo a hipótese dos autos, face a reincidência específica do réu, sem que possa falar na ocorrência de bis in idem (AgRg no AREsp 1810760/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Nessa toada, torno as penas definitivas em tal patamar.

À míngua de maiores elementos sobre a situação econômica do réu e diante de sua aparente hipossuficiência, fixo no patamar mínimo o valor do dia-multa.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada diante da reincidência do réu, além de ser o mais adequado à repressão do tráfico ilícito de entorpecente, delito equiparado aos hediondos, uma vez afastada a sua modalidade privilegiada, e que atemoriza e causa intranquilidade na parcela ordeira da sociedade, na medida em que contribui para o aumento desenfreado da violência, em conexão com outros delitos como furtos, roubos, homicídios, etc., prejudicando milhares de jovens e famílias inocentes, devendo, portanto, ser repreendida de forma enérgica e severa pelas autoridades judiciárias.

A hediondez do crime e a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada vedam a sua substituição por restritivas de direitos, bem como a concessão do benefício da

suspensão condicional da pena, além de tais medidas não se mostrarem suficientes e adequadas no caso concreto, haja vista a postura indiferente adotada pelo agente diante dos efeitos nocivos da droga à saúde pública e ao bem estar social. Deixo de fixar indenização por danos materiais em valor mínimo, pois o delito em apreço não gera efetivo prejuízo material mensurável economicamente. Por fim, uma vez que o acusado respondeu a presente ação em liberdade, melhor que assim aguarde eventual julgamento de recurso em prestígio ao princípio da não culpabilidade.

ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal em epígrafe para o fim de CONDENAR o acusado JOÃO PEDRO MARQUES DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando a pena privativa de liberdade de 5(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além da pena pecuniária de 583(quinhetos e oitenta e três) dias multa, no valor unitário mínimo legal.

Arcará o réu com as custas processuais no valor correspondente à 100 UFESP's.

Não comprovada a origem lícita do numerário apreendido nos autos (p.82/83), decreto sua perda em favor da União (Lei 11.343/06, art.63)

Com o trânsito em julgado, oficie-se para destruição das amostras guardadas para contraprova conforme o disposto no art. 525 das NSCGJ-" Encerrado o processo penal ou arquivado o inquérito policial ou termo circunstanciado, o juiz determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova, não podendo os autos serem remetidos ao arquivo sem a respectiva comunicação."

Por fim, arbitro honorários advocatícios ao n. Defensor nomeado nos autos no valor máximo da tabela atualizada do convênio DPESP/OAB para a situação, expedindo-se certidão oportunamente.

P. I. C.

São Manuel, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA